

1510322-34.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... - Sexta Turma, DJe em: 31/08/2022).

O roubo restou consumado.

No momento em que os agentes anunciaram o roubo e subjugaram o ofendido, houve inversão da posse dos bens roubados e do veículo. E a maior parte dos bens não foi recuperada, o que impede se cogitar a tentativa.

Nesse sentido: "Roubo - tem-se como consumado se subtraída a coisa, mediante violência ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510322-34.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510322-34.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS AUGUSTO PEIXOTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

DENIS AUGUSTO PEIXOTO e JULIO CESAR GOMES MOREIRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 1º de maio de 2022, por volta das 13h50, na Avenida Paula Ferreira, nesta capital, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Suzuki Bandit 650, placas FLW5939, avaliada em R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); um relógio de pulso avaliado em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); um capacete avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); um aparelho celular da marca Samsung, modelo A30, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); e documentos pessoais, bens pertencentes a M. R. da S..

Recebida a denúncia (págs. 92/93), os réus foram citados e apresentaram resposta escrita à acusação (pág. 114), subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos. Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, interrogando-se os réus ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que

a Dra. Promotora de Justiça e o Dr. Assistente da Acusação insistiram na condenação, nos exatos termos da denúncia.

Os Drs. Defensores, por sua vez, levantaram preliminar de nulidade do reconhecimento levado a efeito em solo policial, por inobservância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pugnaram pela absolvição e sustentaram, em síntese, que a prova produzida é precária. Alternativamente, requereram: (I) fixação das penas-base no mínimo legal; (II) aumento na fração mínima por conta da reincidência de DENIS; (III) afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; (IV) aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; (V) desclassificação do crime denunciado para a figura típica do artigo 180 do Código Penal; (VI) regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena; (VII) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com relação a JULIO CESAR; e, por fim, (VIII) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, indefiro a diligência postulada pela Douta Defesa de JULIO CESAR, que requereu a expedição de ofício à Polícia Militar para “encaminhar o BOPM via COPOM” (pág. 269), uma vez que referido documento já foi juntado às págs. 180/188 dos autos, constando nele, ainda, o horário da comunicação dos fatos.

No mais, afasto a preliminar levantada pelas Dras. Defensoras, que sustentam nulidade do reconhecimento levado a efeito em solo policial.

Com efeito, inexistente o vício apontado, uma vez que, conforme se verifica da simples leitura do auto de reconhecimento formalizado na delegacia de polícia (pág. 29), a vítima “descreveu os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida”. Na sequência, “em local onde se encontravam várias pessoas”, identificou os acusados, com absoluta segurança, como dois dos responsáveis pelo crime, de modo que bem preenchidas todas as formalidades elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Não fosse assim, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que as disposições do artigo 226 consubstanciam-se em meras recomendações legais, a serem observadas quando possível.

Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que ‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei’” (STJ - AgRg no HC 724859/SC, Relator(a): Min. RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, DJe em: 08/04/2022).

Por todo o exposto, referida preliminar fica afastada.

No mérito, procede integralmente a presente ação penal.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 04 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 05/09); auto de reconhecimento de pessoa (pág. 29); auto de exibição, apreensão e entrega (págs. 30/31); fotografia da motocicleta apreendida (pág. 32); BOPM (págs. 180/188); e sobretudo pela contundente prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, nas oportunidades em que foram ouvidos, os acusados negaram o cometimento do crime.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda no calor dos fatos, perante a D. Autoridade Policial, ambos narraram que: “(...) Nega veementemente os fatos, alegando inocência. Afirma que reside próximo ao local onde a moto foi encontrada, sendo que a mesma encontrava-se estacionada entre dois carros, próximo ao local onde caminhavam quando a polícia militar chegou e o abordou, sendo que os policiais afirmaram que o mencionado veículo estava em sua posse. Nega ter participado do roubo da moto, encontrando-se em local diferente, no horário dos fatos” (págs. 17 e 18).

Em Juízo, da mesma forma, negaram a imputação, mas prestaram outros esclarecimentos.

Desta vez, JULIO CESAR narrou que, no dia dos fatos, foi buscar sua namorada no serviço e a levou para casa.

Logo que chegou em sua residência, recebeu uma ligação de DENIS, que pediu um favor, ou seja, que lhe desse uma carona até a comunidade para que ele “acertasse um perfume” com a vendedora, porque sua motocicleta estava quebrada. Isto posto, aceitou dar a carona, buscou DENIS e o conduziu até o local combinado com a vendedora. Lá chegando, estacionaram a motocicleta em frente a uma padaria e atravessaram a rua, oportunidade em que DENIS ingressou na viela. Enquanto aguardava DENIS na via pública, avistou uma viatura da polícia militar “vindo a milhão”, ao que olhou para o lado e viu “uns cinco ou seis moleques correndo em direção à praça”. Inobstante, ficou parado no local, porque “não devia nada”.

Ato contínuo, referidos policiais o abordaram e, logo após, abordaram DENIS, que havia acabado de retornar da viela.

Relatou que a policial militar feminina ingressou na viela e, depois de um minuto, retornou acusando-os de terem roubado uma motocicleta: “(...) a casa de vocês caiu já, achei a moto, vocês vão para a delegacia.”.

Em seguida, a policial feminina entregou as chaves de sua motocicleta para sua esposa e, em seguida, os conduziu à delegacia de polícia.

Logo que chegaram no distrito policial, a policial feminina deixou o porta-malas aberto, tirou fotografias de ambos e passou a conversar com um homem, que começou a chorar e a abraçar.

Em seguida, esse homem parou em frente à viatura e passou a observá-los enquanto conversava com a policial. Posteriormente, descobriu que este homem era a vítima. Em seguida, foram submetidos ao reconhecimento pessoal e identificados pela vítima como os responsáveis pelo crime, de modo que a Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante.

DENIS, por sua vez, declarou que pediu uma carona para JULIO CESAR, porque precisava ir até uma comunidade com o objetivo de quitar uma dívida referente a um perfume que havia adquirido.

Afirmou que JULIO CESAR aceitou lhe dar a carona e o levou até a comunidade. Lá chegando, desembarcou da motocicleta e foi até o local em que havia marcado de entregar o dinheiro à vendedora – no final da viela. JULIO CESAR, por sua vez, permaneceu o aguardando na via pública.

Após realizar o pagamento, saiu da viela em direção à rua e visualizou policiais militares abordando JULIO CESAR. Em seguida, referidos milicianos também o abordaram – “você também” – e perguntaram se “tinha passagem”, oportunidade em que, por possuir registros criminais, os milicianos “se apegaram bastante ao seu passado”.

Nesse ínterim, a policial militar feminina entrou na viela, avistou alguns rapazes sentados – que saíram andando a passos rápidos – e localizou uma motocicleta: “encontramos uma moto, nós vamos te levar pra delegacia, precisamos fazer uma averiguação, se não for você, você vai sair pela porta da frente”.

Ato contínuo, foram algemados e conduzidos à delegacia de polícia, oportunidade em que a vítima se aproximou da viatura e os avistou ainda dentro do porta-malas do veículo.

Depois desse reconhecimento, a policial militar feminina lhe fez diversas perguntas a respeito de sua altura e tatuagens, bem como tirou uma fotografia, porque “era procedimento de serviço”.

Posteriormente, foram levados ao interior da delegacia de polícia e colocados ao lado de outros três rapazes, oportunidade em que a vítima os apontou como os autores do crime.

Por fim, asseverou que viu os “moleques” que se evadiram da polícia manuseando a motocicleta e afirmou que os conhece, uma vez que eles residem na comunidade.

Mas referidas exculpatórias, por óbvio, são indignas de qualquer credibilidade, refutadas que foram pela prova adversa, sobretudo diante dos firmes relatos prestados pela vítima e do reconhecimento, indene de dúvidas, por ela levado a efeito em solo policial e ratificado em Juízo, daí porque indigna de credibilidade, sem olvidar dos firmes esclarecimentos prestados pelas testemunhas policiais.

O ofendido M. R. da S. narrou, com riqueza de detalhes, como se deu toda a ação criminosa, descrevendo a violência e grave ameaça a que foi submetido, e reconheceu

os réus como os responsáveis, o que fez com bastante segurança.

Aduziu que estava pilotando sua motocicleta pela via pública, levava filha de 10 anos de idade na garupa, e, quando passou por uma lombada, foram abordados por quatro indivíduos, que ocupavam duas motocicletas – dentre eles os acusados. Na sequência, referidos agentes – todos portando armas de fogo –, anunciaram o roubo e subtraíram todos os seus pertences – celular, relógio, capacete e retrovisor, além da quantia de R\$ 400,00 em espécie –, sendo que um deles arrancou seu capacete à força e quase quebrou seu nariz.

Em seguida, um dos criminosos subiu em sua motocicleta, exigiu que "virasse e saísse andando" e quase levou sua filha, que ainda estava na garupa do veículo. Acrescentou que os roubadores chegaram a bater no capacete de sua filha com uma pistola e apontaram a arma de fogo em direção à cabeça dela, de modo que ela ficou bastante traumatizada com a ação, passou a urinar nas calças e não conseguiu mais andar de moto ou de carro.

Finda a ação criminosa, acionou a polícia militar e comunicou o roubo. Algumas horas depois, foi contatado pela polícia e informado que seu veículo havia sido recuperado, na posse de dois indivíduos.

Desta feita, compareceu à delegacia de polícia e realizou o reconhecimento, oportunidade em que identificou os acusados, o que fez com absoluta segurança, como dois dos responsáveis pelo crime.

Por fim, declarou que não recuperou seus pertences – à exceção da motocicleta, que estava sem os retrovisores importados.

E os policiais militares responsáveis pela diligência, nas oportunidades em que foram ouvidos, apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos. Narraram que foram acionados via rede-rádio e comunicados a respeito do roubo de uma motocicleta Suzuki de grande porte, que possivelmente estaria sendo desmontada em uma viela – acrescentando que lhes foram informadas as características físicas de um dos autores do crime.

Esclareceram que o endereço fornecido "(...) é um lugar contumaz no roubo de veículo, os agentes roubam e levam para aquele local para 'esfriar' o veículo, inclusive há indivíduos que avisam quando a viatura desce, é um local bem estratégico".

Por conseguinte, dirigiram-se ao local indicado e, lá chegando, depararam-se com os réus, que estavam manuseando a motocicleta com algumas ferramentas – chave de fenda e fita isolante – e adulterando o emplacamento do veículo.

Quando notaram a presença da guarnição, os réus "(...) se desvencilharam, saíram andando, tentando disfarçar", de modo que procederam à abordagem.

Instados, eles negaram, a princípio, que estivessem manuseando o veículo, justificando que moravam naquele local e estavam saindo da viela. Desta feita, contataram o COPOM e solicitaram mais uma vez as características dos autores do roubo – que coincidiam com as dos réus.

Isto posto, eles acabaram por admitir apenas que sabiam que a motocicleta era roubada, mas não confessaram que estivessem envolvidos no crime.

Desta feita, lhes deram voz de prisão em flagrante e os conduziram à delegacia de polícia, oportunidade em que foram submetidos ao reconhecimento pessoal, que resultou positivo, e foram apontados pela vítima, com absoluta segurança, como dois assaltantes.

Por fim, afirmaram que o local da apreensão da motocicleta ficava a alguns poucos quilômetros de distância do local do roubo.

A testemunha T. G. da S. C. narrou que é amiga dos acusados e teve contato com eles no dia em que foram presos, posto que vendeu um perfume para DENIS e ele foi até a viela para lhe pagar o produto.

Na oportunidade, DENIS lhe informou que "JULIO CESAR deu uma carona para ele, tava junto com ele", sendo que o corréu o aguardava fora da viela.

Por fim, declarou que notou um "alvoroço" na comunidade e soube que eles foram presos, mas não visualizou o momento da prisão, porque estava dentro da residência de uma amiga.

Por derradeiro, a testemunha E. de M. S. declarou que presenciou a abordagem policial.

Afirmou que estava próxima a uma adega e avistou JULIO CESAR e DENIS chegando no local em uma motocicleta, a qual era conduzida por JULIO CESAR. Em seguida, JULIO CESAR estacionou o veículo e ficou no local aguardando DENIS - que desembarcou da motocicleta e ingressou em uma viela. Pouco após, DENIS retornou da viela e foi abordado por policiais militares junto de JULIO CESAR. Relatou que havia algumas pessoas na via pública, que correram quando avistaram a guarnição.

Por fim, asseverou que havia uma outra motocicleta na via pública, "(...) não muito distante a eles", sendo que algumas pessoas a manuseavam. Inobstante, não chegou a ver se os réus mexeram nesse veículo.

Como já consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do delito, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade dos acusados, que rechaçaram a imputação, mas apresentaram fantasiosas, inconsistentes e frágeis negativas de autoria.

Assim é que justificaram que foram abordados pelos policiais militares e acusados injustamente de terem praticado o roubo aqui tratado, sem qualquer motivo aparente, apenas porque estavam próximos à motocicleta roubada e pelos antecedentes de JULIO CESAR..

Ainda, procuraram convencer que o reconhecimento levado a efeito foi viciado, uma vez que a policial militar feminina os fotografou e, na sequência, levou o ofendido até a viatura, oportunidade em que permitiu que os visse antes mesmo de formalizar o reconhecimento perante a Autoridade Policial.

Mas nem de longe comprovaram essas versões, como lhes competia fazer, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Ao contrário, essas versões exculpatórias foram absolutamente infirmadas pelo seguro relato da vítima, que descreveu com minúcias as circunstâncias do crime e reconheceu os réus, com absoluta segurança, como os responsáveis.

E os esclarecimentos prestados pela vítima são merecedores de toda credibilidade, porque, tratando-se de pessoa isenta, não teria qualquer interesse em prejudicar injustamente inocentes, que sequer conhecia.

Nesse sentido: "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente" (TACRIM-SP - AC - rel. Clineu Ferreira - JUTACRIM 90/318).

Não bastasse, os policiais militares inquiridos prestaram depoimentos absolutamente coerentes, embasando o relato das vítimas, o que deu ensejo à formação de um robusto conjunto probatório, a autorizar um decreto condenatório estreme de dúvidas.

E não existe demonstração probatória de qualquer interesse desses policiais militares em prejudicar pessoas inocentes, não havendo daí motivo para que essa prova seja desprezada.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram.

Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Desta forma, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pela vítima e o reconhecimento pessoal por ela formalizado nas duas fases do procedimento, bem como as declarações dos policiais militares responsáveis pela diligência, levam à convicção segura da responsabilidade dos réus pelo crime, de forma que não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa.

Ademais, o roubo é crime contra o patrimônio e os acusados foram surpreendidos na posse da res, o que gera presunção de responsabilidade e inverte o ônus da prova. E, como já se decidiu: "Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se a justificativa inequívoca, de modo que explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório" (TACRIM-SP - AC - Rel. Norberto Mortari - RJD 18/47).

Por derradeiro, os esclarecimentos prestados pelas testemunhas de Defesa T. G. da S. C. e E. de M. S. em nada alteraram o quadro probatório, uma vez que não presenciaram os fatos aqui tratados.

E em que pese as alegações da Dra. Defensora de JULIO CESAR - no sentido de que o acusado estaria em outro local no momento do roubo -, não há provas de que ele seja a pessoa que aparece nas fotografias de págs. 274 e 279/281 e na mídia juntada à pág. 278.

Mas ainda que se considere que o indivíduo em questão seja, de fato, o acusado, e que o horário corresponda à realidade, de se ressaltar que o local do cometimento do roubo fica a 14 (catorze) minutos de distância do local em que foi encontrada a motocicleta, conforme se verifica do extrato do Google Maps juntado pela Defesa à pág. 277 - máxime considerando que os acusados estavam em uma motocicleta, veículo que sabidamente não se sujeita ao trânsito da capital, não havendo nenhuma incompatibilidade com o horário - frise-se, aproximado - informado pela vítima.

Por fim, impende destacar que as afirmações dos réus no sentido de que foram fotografados e reconhecidos pela vítima no porta-malas da viatura da polícia militar, antes mesmo do reconhecimento pessoal, restaram absolutamente isoladas nos autos, não tendo sido corroborados por quaisquer elementos de convicção.

E não comporta acolhimento a pretensão alternativa da Defesa de JULIO CESAR, que postula a desclassificação do crime denunciado para a figura típica prevista no artigo 180 do Código Penal.

Como dito, a situação flagrancial se deu pelo roubo e a vítima reconheceu os acusados, com absoluta segurança, como os autores do crime. Não bastasse, horas após o roubo, os acusados foram detidos na posse do veículo, o que inverte o ônus da prova.

Logo, ao acusado competia a produção de prova da mera posse do automóvel ciente de que se tratava de produto de crime, mas, ao contrário, JULIO CESAR sequer admitiu a posse do veículo, o que impede o acolhimento da pretensão alternativa formulada.

Por esses argumentos, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

As majorantes denunciadas ficam reconhecidas.

Os acusados agiram numa perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas entre si e com ao menos outros dois agentes não identificados, o que restou demonstrado porque estavam juntos, abordaram, ameaçaram e agrediram as vítimas, subtraíram os pertences de valor - celular, relógio, capacete, retrovisor, dinheiro e motocicleta - e se evadiram na posse dos bens.

Ademais, para compor a ameaça, fizeram uso de ao menos quatro armas de fogo, conforme os firmes esclarecimentos prestados pela vítima.

E a fala da vítima é o que basta para o reconhecimento dessa circunstância: "Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (TJ-SP - Ap. - Rel. Egidio de Carvalho - j. 09.12.1996 RT 741/610).

E ainda: "Para a caracterização do delito de roubo qualificado previsto no inc. I do § 2.º, do art. 157 do CP, não há necessidade de que seja examinada e sequer apreendida a arma utilizada no crime, exigindo-se, apenas a prova de que houve utilização de ameaça para intimidar a vítima e anular-lhe a resistência" (TACRIM-SP - Rev. Rel. Canellas de Godoy - j. 14.04.1998 - RJTACRIM 40/401).

E em se tratando de simulacro ou artefato inoperante, o ônus da prova a respeito é dos acusados, nos moldes do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido: "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal." (STJ - AgRg no AREsp 2076555/RS, Relator(a): Min. Joel Ilan Paciornik, T5 - Quinta Turma, DJe em: 26/08/2022).

"A comprovação da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal prescinde de apreensão e perícia do artefato bélico, podendo o julgador formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios" (STJ - HC 728901/SC, Relator(a): Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, DJe em: 31/08/2022).

O roubo restou consumado.

No momento em que os agentes anunciaram o roubo e subjugaram o ofendido, houve inversão da posse dos bens roubados e do veículo. E a maior parte dos bens não foi recuperada, o que impede se cogitar a tentativa.

Nesse sentido: "Roubo - tem-se como consumado se subtraída a coisa, mediante violência ou grave ameaça, não obstante a subsequente e imediata prisão em flagrante dos autores do crime" (STF - RE - Rel. Célio Borja - RTJ 119/853).

Demonstrada, portanto, a ocorrência do crime, e comprovada a autoria, o desfecho condenatório é mesmo o único viável.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Os documentos juntados aos autos (certidão e F.A. juntadas às págs. 85/87 e págs. 79/82, respectivamente) dão conta de uma condenação definitiva suportada por DENIS, oriunda da 30ª Vara Criminal desta capital, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/04/2021, que será considerada para fins de reincidência.

JULIO CESAR, por sua vez, era tecnicamente primário à época dos fatos.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não lhes são inteiramente favoráveis.

No caso em apreço, os acusados agiram de forma bastante violenta, covarde e cruel, escolheram a vítima que estava acompanhada de uma criança de 10 (dez) anos de idade e deflagraram violenta ação, posto que quase quebraram o nariz da vítima com a brutalidade que utilizaram para arrancar seu capacete e chegaram a dar coronhadas no capacete da criança, bem como apontar as armas de fogo em direção à sua cabeça. E a violência empregada foi totalmente desnecessária, posto que as vítimas já estavam rendidas, incapazes de reagir frente a ameaça com emprego de armas de fogo, o que demanda maior censura no que se refere às circunstâncias e consequências do crime, notadamente diante da conduta social deturpada e a personalidade cruel dos réus.

No mais, de se ressaltar que a filha de M. R. dos S. ficou extremamente traumatizada com o ocorrido, passou a urinar nas calças e não consegue mais andar de carro ou de motocicleta, de forma que é submetida a acompanhamento psicológico.

Por esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, especialmente circunstâncias e consequências do crime, personalidade cruel e conduta social nociva dos réus, fixo a pena-base de cada um deles em 1/2 acima do mínimo legal, ou seja, em seis anos de reclusão e quinze dias-multa.

Por força da menoridade relativa de JULIO CESAR, já que o acusado tinha menos de 21 anos de idade à época dos fatos, atenuo a reprimenda em 1/6, resultando em cinco anos de reclusão e doze dias-multa.

De se reconhecer, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, já que uma das vítimas era criança (10 anos de idade), fato demonstrado no contraditório (artigo 385, parte final, do Código de Processo Penal). Referida circunstância, embora não capitulada, veio perfeitamente descrita na denúncia, o que possibilitou aos réus a ampla defesa, nos exatos termos do que estabelece o artigo 383 do Código de Processo Penal.

Logo, agravo a reprimenda de JULIO CESAR à razão de 1/6, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e catorze dias-multa,.

Com relação a DENIS, pelo concurso de duas agravantes, já que o acusado é reincidente, agravo a pena em 1/5, totalizando sete anos, dois meses e doze dias de reclusão e dezoito dias-multa.

Pelo reconhecimento da majorante do concurso de agentes, a pena será aumentada à razão de 1/3, resultando, para JULIO CESAR em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa; e para DENIS em nove anos, sete meses e seis dias de reclusão e vinte e quatro dias-multa.

Em razão da incidência da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, aumento as reprimendas em mais 2/3, tornando-as definitivas : para JULIO CESAR em doze anos, onze meses e dezesseis dias de reclusão e trinta dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal; e para DENIS em dezesseis anos de reclusão e quarenta dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal.

E não há que se falar em aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do magistrado, inaplicável diante das circunstâncias do caso concreto, pelas razões já consignadas por ocasião da fixação da pena-base. Os quatro roubadores portavam arma de fogo, não satisfeitos após terem subjugado as vítimas, ainda usaram uma delas para apontar para a cabeça e bater no capacete que era usado pela criança, o que, por certo, torna a conduta mais grave e impede a aplicação do referido dispositivo legal.

Nesse sentido: "ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes e em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas". (TJ-SP - AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Ainda: Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento". (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido". (TJ-SP - AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move

contra DENIS AUGUSTO PEIXOTO, R.G. nº 42.933.358, e JULIO CESAR GOMES MOREIRA DA SILVA, R.G. nº 52.786.889, e os condeno - o primeiro, DENIS - ao cumprimento de dezesseis anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quarenta dias-multa; e o segundo, JULIO CESAR - ao cumprimento de doze anos, onze meses e dezesseis dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a trinta dias-multa, ambos por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Tendo em vista a natureza do roubo, que foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - crime hediondo -, o que revela periculosidade de seus executores, os acusados não poderão recorrer em liberdade, deverão ser recomendados na prisão em que se encontram e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

E de regime mais brando não há que se falar, nos termos da r. decisão proferida pelo i. Desembargador Luiz Soares de Mello, colacionada em apelação Criminal nº 1.439-961-1, da E. 6ª Câmara do tribunal de Alçada Criminal, relator Maia da Cunha: "Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, "data vênia", com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser e nem foi, no caso com a sociedade onde vive e com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcerar o cidadão que merece ser encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizados." (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807).

Pelas razões acima consignadas por ocasião da fixação da pena base, bem como por tudo quanto produzido no contraditório, presentes os requisitos legais, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada, uma vez que persistem as situações que motivaram a medida, nos termos do que estabelece o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ademais, a prisão se mostra necessária, inclusive, para assegurar o cumprimento da pena aplicada (artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal).

É certo que os acusados estão presos desde 02 de maio deste ano, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), por se tratar de matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei nº 7.210/84 - detração penal, com observância ao que dispõe o artigo 112 e § 1º, da mesma lei.

Nesse sentido: "Por fim, inaplicável o artigo 387, parágrafo 2º, do Diploma Processual, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira obliqua, de verdadeira e inoportuna progressão" (Apelação nº 0007336-26.2011.8.26.0663. Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).

Condeno os acusados ao pagamento das custas do processo, nos termos do que estabelece o artigo 804 do Código de Processo Penal. Eventual pleito de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, momento oportuno para verificação de forma mais detalhada acerca da capacidade financeira dos réus (STJ 6ª Turma, REsp 1.637.275/RJ).

Após o trânsito em julgado, sejam os nomes dos réus lançados no rol dos culpados. P.R.I.C.

São Paulo, 05 de outubro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA